

1500159-39.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... caderno com anotações da contabilidade do tráfico, além da CNH de Fabiano, conhecido pela prática do tráfico, que segundo Cauany seria seu namorado, que também reside no local e estava ausente. Cauany disse que a droga pertencia à seu namorado Fabiano e que recebia R\$ 500,00 (quinhentos reais) dele para armazenar e vender as drogas.

A testemunha de defesa, Tainá Maria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500159-39.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500159-39.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2057213/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 23308212 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 694/22/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2057213 - DEL.POL.SALTO, 694/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAUANY ORTIZ LEANDRO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra a ré CAUANY ORTIZ LEANDRO DA SILVA, por infração ao artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (nas imediações de estabelecimento de ensino), ambos da Lei nº 11.343/06. R da Lei nº 11.343/06 porque, em tese, no dia 1º de março de 2022, por volta das 01h35min, na Rua Jacarandá, nº 381, Jardim Santa Terezinha, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP, a acusada trazia consigo, guardava e tinha em depósito para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 01 (uma) garrafa plástica, contendo resquícios de "cloroformo de metileno/diclorometano", substância entorpecentes popularmente conhecida como "lança-perfume"; b) 03 (três) tijolos de

"tetrahidrocannabinol", vulgarmente conhecido como "maconha", acondicionados em invólucros plásticos, com peso líquido de 700,35g (setecentas gramas e trinta e cinco centigramas); c) 01 (uma) porção de "cocaína", com peso líquido de 151,26g (cento e cinquenta e um gramas e vinte e seis centigramas); d) 08 (oito) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas); e) 35 (trinta e cinco) porções "cocaína", em sua forma petrificada, conhecida popularmente como "crack", acondicionadas em invólucros plásticos, com peso líquido de 92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois centigramas); e f) 01 (um) comprimido de "metanfetamina", também conhecido como "ecstasy" com peso líquido de 0,38g (trinta e oito centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 11 de abril de 2022 (fls. 88-93).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 105-106).

A denúncia foi recebida em 08 de junho de 2022 (fls. 109-110).

Durante a instrução processual foram inquiridas duas testemunhas comuns, uma arrolada pela defesa e a ré foi interrogada. Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição da acusada em razão da ilegalidade da atuação dos guardas municipais. Alternativamente, postou a aplicação das atenuantes da menoridade e confissão, a aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas e substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição e apreensão (fl. 06-07), auto de constatação preliminar (fl. 09-10), laudo pericial em peças (fls. 72-74), laudo de exame químico toxicológico (fls. 81-84), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

As testemunhas comuns Diego Guiaro de Moraes e Claudemir Tenório da Silva, guardas municipais, foram uníssonos ao afirmarem em Juízo que estavam em patrulhamento quando visualizaram uma mulher andando em sentido contrário à viatura, colocando algo dentro da blusa, o que motivou a abordagem. Foi identificada como Cauany e indagada sobre o que teria guardado na blusa, retirou um pedaço de jornal contendo 12 pequenas porções de "crack" embaladas em plástico e uma porção de cocaína, também embalada em plástico, além de 1 aparelho celular e R\$ 190,00 (cento e noventa reais) atrás da capa do aparelho. Ao conduzirem a acusada até sua residência para que pegasse seus documentos, ela admitiu que no interior do imóvel havia mais drogas e dinheiro. Na residência, Cauany indicou na cozinha onde estavam armazenadas as drogas, sendo: 8 porções pequenas de cocaína e outra maior, empedrada, também de cocaína; 3 pedaços de tijolos de maconha; 20 porções pequenas de crack; 3 pedras grandes de crack; uma garrafa de plástico com menos da metade com produto transparente, possivelmente utilizado como "lança perfume"; um comprimido azul de "ecstasy". Na cozinha ainda foram encontrados uma balança de precisão, um rolo de filme plástico para embalagem, 2 facas com resquícios de drogas, 1 colher com resquícios de drogas. No quarto, indicou uma caixa de relógio contendo R\$ 1898,00 (mil oitocentos e noventa e oito reais), 1 caderno com anotações da contabilidade do tráfico, além da CNH de Fabiano, conhecido pela prática do tráfico, que segundo Cauany seria seu namorado, que também reside no local e estava ausente. Cauany disse que a droga pertencia à seu namorado Fabiano e que recebia R\$ 500,00 (quinhentos reais) dele para armazenar e vender as drogas. A testemunha de defesa, Tainá Maria Aparecida Vieira, em juízo, apresentou depoimento abonatório da conduta da acusada.

A ré, interrogada judicialmente, confessou os fatos a ela imputados. Disse, em resumo, que foi abordada por guardas municipais que encontraram com ela a droga que trazia consigo. Os guardas pressionaram e ela indicou onde estava o restante das drogas. No interior da casa em que estava ficando, de um amigo dela, indicou onde estavam as drogas.

A confissão da ré foi satisfatoriamente corroborada pelos depoimentos das testemunhas inquiridas em juízo, guardas municipais que participaram da ocorrência. Esses testemunhos autorizam o reconhecimento da autoria do crime de tráfico, anotando-se que a acusada foi surpreendida pelos agentes enquanto trazia consigo, ente as vestes, um pedaço de jornal contendo 12 pequenas porções de "crack" e uma porção de cocaína, um aparelho celular e R\$ 190,00 (cento e noventa reais) e, ainda, guardava e tinha em depósito em sua residência, 8 porções de cocaína e outra maior, empedrada, também de cocaína; 3 pedaços de tijolos de maconha; 20 porções pequenas de crack; 3 pedras grandes de crack; uma garrafa de plástico de "lança perfume", um de "ecstasy", além de balança de precisão, um rolo de filme plástico para embalagem, 2 facas com resquícios de drogas, 1 colher com resquícios de drogas, R\$ 1898,00 (mil oitocentos e noventa e oito reais), 1 caderno com anotações.

As declarações do guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

Além disso, cuida-se de crime permanente e, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, considerando, ademais, que a prisão decorreu de abordagem, sem qualquer investigação prévia, de modo que inexistente óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar a ré. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

TRÁFICO ILÍCITO E ASSOCIAÇÃO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória. Prejudicado pelo julgamento Colegiado. Suposta prova lícita. Desnecessidade de mandado em se tratando de crime permanente. Prisão por Guarda Municipal. Possibilidade. Inteligência da Lei nº 13.022/14 (Estatuto das Guardas Civis). Rejeição. ART. 33, CAPUT. Absolvição Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. ART. 35, CAPUT. Reversão da condenação. Viabilidade. Não demonstração de estabilidade e caráter duradouro. Mero concurso de agentes. DOSIMETRIA. Redução do aumento na primeira etapa de DOUGLAS. Afastamento da reincidência (trânsito em julgado afastado pelo HC nº 2290149-29.2020.8.26.0000, j. 19/3/2021, 8ª Câmara, TJSP). Manutenção da agravante da calamidade. Reconhecimento da menoridade relativa de DENILSON. Penas de DOUGLAS e DENILSON reduzidas. Inaplicabilidade da benesse do art. 33, § 4º. Regime fechado preservado. ISENÇÃO DAS CUSTAS. Inviabilidade. Inteligência da Lei nº 1.060/50 e Lei Estadual nº 11.608/03. PROVIMENTO PARCIAL. (TJSP; Apelação Criminal 1501786-81.2020.8.26.0526; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 07/10/2021; Data de Registro: 08/10/2021). As circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade, variedade e a natureza das drogas apreendidas, aliadas ao encontro de dinheiro e de objetos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas, além da confissão, indicam que as drogas apreendidas eram destinadas à entrega e a consumo de terceiros, evidenciando o intuito mercantil, sendo suficientes a embasar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido, tem-se o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Confissão e validade das palavras dos policiais. Se o tráfico foi praticado nas imediações de escola, mas em horário ermo ou em dias em que não há aula, deve ser, excepcionalmente, afastada a majorante do art. 40, III, da Lei de Tóxicos. Condenação acertada. Decretação da extinção da punibilidade de Vinicius pelo integral cumprimento da pena. Redução da reprimenda de João Lucas. Réu primário.

Natureza e quantidade do tóxico que devem ser avaliadas em conjunto, e não isoladamente, para aferição do potencial danoso. Concessão do redutor do art. 33, § 4.º, da Lei de Tóxicos na fração intermediária. Possibilidade de fixação do regime aberto. Réu primário e hediondez do chamado tráfico privilegiado que foi afastada pelo pleno do E. STF. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e outra de multa. Recurso de Vinicius provido, parcialmente provido o de João Lucas e improvido o do Ministério Público. (TJ-SP - APR: 15001181520198260622 SP 1500118-15.2019.8.26.0622, Relator: Francisco Bruno, Data de Julgamento: 09/03/2021, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/03/2021).

Por outro lado, impositivo reconhecimento da atenuante da confissão e menoridade da ré que, à época dos fatos, de acordo com documento hábil fls. 20, contava com 18 anos.

Anoto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, firmou entendimento de que "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual. Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como grande quantidade de droga, deve utilizar esse critério para operar uma menor diminuição da pena, deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, não obstante a ré ser primária (fls. 126) e não restar provado que integre organização criminosa (a prisão resultou de atuação da guarda municipal, em razão de situação flagrancial, sem que houvesse qualquer diligência investigativa prévia) cabe destacar a variedade e quantidade expressiva de drogas apreendida, qual seja: a) 01 (uma) garrafa plástica de "lança-perfume"; b) 03 (três) tijolos de "maconha" com peso líquido de 700,35g (setecentos gramas e trinta e cinco centigramas); c) 01 (uma) porção de "cocaína", com peso líquido de 151,26g (cento e cinquenta e um gramas e vinte e seis centigramas); d) 08 (oito) porções de "cocaína", com peso líquido de 11,32g (onze gramas e trinta e dois centigramas); e) 35 (trinta e cinco) porções "cocaína", em sua forma petrificada, conhecida popularmente como "crack", com peso líquido de 92,52g (noventa e dois gramas e cinquenta e dois centigramas); e f) 01 (um) comprimido de "ecstasy". com peso líquido de 0,38g (trinta e oito centigramas), tudo a justificar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos em 1/6 (um sexto).

Finalmente, em se tratando de crime de tráfico de drogas, consoante artigo 63 da Lei nº11.343/2006, o perdimento de qualquer bem e valor apreendido nos autos, em favor do FUNAD, é efeito da condenação, na forma do artigo 91, caput, do Código Penal. No mesmo sentido, a Constituição Federal, em seu art. 243, parágrafo único, dispõe que todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá em benefício de instituições e pessoal especializados no tratamento e recuperação de viciados e no aparelhamento e custeio de atividades de fiscalização, controle, prevenção e repressão do crime de tráfico dessas substâncias

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 647 dar repercussão geral, por maioria, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. (RE638491/PR, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 17/05/2017).

Dessa forma, considerando que compete ao réu a prova da origem lícita dos objetos e valores apreendidos (art. 60, § 1º, da Lei 11.343/2006), e, tendo em vista que a sentenciada não se desincumbiu do seu ônus, decreto o perdimento do celular Xiaomi, pertencente à ré e da importância em dinheiro, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a ré é primária, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime não devem ser valoradas negativamente diante da variedade e quantidade de droga apreendida, evitando-se a ocorrência de bis in idem, a quantidade será valorada na terceira fase da dosimetria, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, por ter sido o crime praticado na imediação de escola (fls. 92) aumento a pena em 1/6 fixando-a em 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Considerando a primariedade e o não envolvimento da ré com nenhuma organização criminosa, mas levando em conta a quantidade e variedade de droga apreendidas, com fundamento no § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 1/6, obtendo a pena final de 4 anos, 10 meses e 10 dias, e 485 dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante da quantidade das penas aplicada, sendo a ré primária, o regime é o semiaberto (artigo 33 do Código Penal) e incabível a substituição por pena restritiva de direitos.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR a ré CAUANY ORTIZ LEANDRO DA SILVA, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias, em regime semiaberto, e 485 dias-multa, no valor mínimo legal pela prática do crime previsto no artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Considerando que a ré permaneceu solta no curso do processo e, ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concedo o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não estiver presa.

Decreto o perdimento do celular Xiaomi, pertencente à ré e da importância em dinheiro, a serem revertidos ao FUNAD (art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006).

Arcará a ré, ainda, com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se

Salto, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA